

1501348-85.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... no local que é um ponto conhecido de tráfico. Ao ser abordado, ele correu, mas foi abordado e com ele localizada uma pochete com drogas e dinheiro, tendo confessado que estava traficando. Com a chegada de outros policiais, estes alegaram que o réu praticava roubos, o que foi por ele confirmado, e alegou ter ido para o tráfico por ser menos arriscado para a vida dele. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501348-85.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/000973

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2183721/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 18923332 - 03º D.P. DIADEMA, 2266/21/127 - 03º D.P. DIADEMA, 2183721 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Vito Henrique Boccuzzi

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

VITO HENRIQUE BOCCUZZI, qualificado à fl. 17, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia no dia 07 de julho de 2021, por volta das 07h30, na Travessa Primeiro de Outubro, n.º 19, bairro Campanário, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 111 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 51 gramas, 73 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 26 gramas e 64 invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 166,0 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20 e laudo de constatação provisória de fls. 08/11.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl.48/51), o réu foi citado e apresentou defesa preliminar as fls.139/141, através do Defensor Público que lhe foi nomeado, pugnando pela absolvição sumária, sem arrolar testemunhas diversas da Acusação. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 22/10/2021 (fls.142).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, em que pese a confissão do réu, relativamente menor, podendo ser afastada a agravante da calamidade publica, mas discordando da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional no mínimo intermediário.

Já o d. Defensor Público reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, afastando-se a agravante da pandemia da Covid19, reduzindo a pena ainda que em patamar menor, com sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede, com exceção da agravante da calamidade publica a ser afastada.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl. 24, nos autos de constatação e no definitivo (fls.11/14 e 184/186), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha, além das anotações da contabilidade do tráfico (fls. 181/183).

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos milicianos (fls.06/08), efetuavam patrulhamento ostensivo preventivo pelo local descrito na denúncia e visualizaram um individuo carregando nas costas uma mochila e trazia também uma pequena bolsa na transversal do corpo, demonstrando nervosismo e inquietude ao ver a viatura. Proferiram voz de parada ao individuo que não obedeceu e tentou evadir-se, sendo detido logo em seguida após cerca de 2 metros. Procedida a busca pessoal, no interior da mochila localizaram 64 tabletes de erva esverdeada com características de Maconha, 111 invólucros plásticos contendo substância em pó branca com características de Cocaína e 73 Invólucros plásticos contendo pedras amareladas com características de Crack, e no interior da bolsa que ele carregava junto ao corpo, localizaram a quantia de R\$ 190 em diversas notas e R\$ 13,25 em moedas, um caderno com anotações típicas de contabilidade de tráfico e um aparelho celular, marca Iphone. Indagado informalmente, ele afirmou que estava traficando drogas naquele local desde as 20hs da noite anterior.

Sob o crivo do contraditório o policial Felipe de Brito confirmou que o local é um

ponto de venda de drogas e resolveram fazer patrulhamento e avistaram o réu, por si reconhecido. Ele estava parado e assim que entraram, espantou os compradores e o réu foi flagrado com uma mochila contendo drogas - crack, cocaína e maconha em bastante quantidade, mais dinheiro em notas diversas.

Igualmente o miliciano Tiago da Silva Ré alegou que estavam patrulhando no local que é um ponto conhecido de tráfico. Ao ser abordado, ele correu, mas foi abordado e com ele localizada uma pochete com drogas e dinheiro, tendo confessado que estava traficando. Com a chegada de outros policiais, estes alegaram que o réu praticava roubos, o que foi por ele confirmado, e alegou ter ido para o tráfico por ser menos arriscado para a vida dele.

O réu, em solo policial (fl. 09) respondeu que é usuário de drogas e que recebe trinta por cento do valor da venda. Disse não saber informar o nome do fornecedor das drogas.

Em juízo o acusado disse ter traficando três dias nessa localidade, e na abordagem foi sincero com os policiais, e está arrependido.

Logo, as confissões informal, extrajudicial e a feita perante o juiz imparcial não é prova única e veio corroborada pelos depoimentos dos milicianos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, das anotações da contabilidade do tráfico, tudo sem prova contrária.

Ressalto o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Ainda que não presenciado o réu efetivamente vendendo droga, é certo que o crime do art. 33 da Lei de Drogas é de tipo múltiplo e uma das condutas ali previstas já caracteriza o delito, que no caso em tela foi a conduta de trazer consigo drogas para a venda, ainda que o réu alegue ser usuário, o que não foi provado e nem afasta a traficância, que geralmente coexiste para o sustento do vício.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína/crack), a quantidade de narcóticos (248 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), a apreensão de dinheiro proveniente do tráfico (fls. 58/59), são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável. Ainda que se trate de agente que se diz usuário, situações que não se opõe, e sim coexistem.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, a má personalidade do agente que tem medidas sócio educativas aplicadas quando adolescente a indicar que faz do crime seu meio de vida como se depreende de fl. 83/87 e 88/89, assim como a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (248 invólucros no total) o que reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão a reduzir a pena ao mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, pois ausentes circunstâncias agravantes, não havendo prova cabal da majorante do art. 61, II, "j", do CP, pois embora os fatos tenham se dado em época da pandemia pelo Covid 19, não há prova cabal de que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, dessa situação especial à prática delitiva, ou que tenha se valido da facilidade que dela decorreu. Neste sentido vide: Por unanimidade, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a agravante de crime cometido em período de calamidade pública, conforme o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois, segundo o relator, desembargador Andrade Sampaio, "não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19" (TJ-SP / Proc. 1512067-20.2020.8.26.0228).

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, quer pelo maior envolvimento do réu com o crime, como as certidões de antecedentes criminais (fls.83/89 e 119/121) assim o demonstram, consoante medidas sócio educativas que lhe foram aplicadas, somado ao numerário apreendido (fl. 58/59), proveniente da mercancia ilícita de narcóticos, disseminando o vício entre os usuários, há três dias como afirmado pelo réu, quem tinha até anotações da contabilidade do tráfico a não deixar dúvidas de que integrava uma verdadeira organização voltada à mercancia ilícita. Ademais, é possível o afastamento da minorante do art. 33, §4º da Lei Antidrogas com base em ato infracional (EResp 1.916.596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por maioria, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021). Neste sentido, ainda: Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. (...) MÉRITO. 1. Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico de drogas. 2. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. A prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Precedentes do STJ. 3. Sanção que não comporta reparo. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1500078-39.2018.8.26.0599; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019). E o que dirá à prática de atos infracionais por roubos e furto.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a primariedade do réu de um lado, e a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o semiaberto, com o que inclusive está de acordo o Parquet.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausente o requisito objetivo (pena supera 4 anos). Ademais: "Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime." (TJAP) RT 772/617.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS

Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há seis meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC nº 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra VITO HENRIQUE BOCCUZZI, qualificado à fl. 17, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e o faço para condená-lo à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

ABSOLVO o acusado VITO HENRIQUE BOCCUZZI, qualificado à fl. 17, das penas do art. 61, II, j, do CP, com fulcro no art. 386,VII, CPP.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere compatível com o regime ora fixado .

Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora, nos termos da Lei estadual nº 11.608 de 2003.

Decreto a perda do numerário apreendido (fl.58/59), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA